

1503029-94.2021.8.26.0180

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ROSELI JOSE FERNANDES COUTINHO

Comarca: Espírito Santo do Pinhal

Foro: Foro de Espírito Santo do Pinhal

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 31/03/2022

... parcial da ação penal. O crime de tráfico de drogas restou demonstrado visto que os acusados foram flagrados em plena prática da infração livremente cometida, além da forma em que as drogas estavam acondicionadas (porções individualizadas) e variedade (crack e maconha). Lado outro, quanto ao crime de associação ao tráfico diante da inexistência de provas seguras que possam ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Espírito Santo do Pinhal

Foro de Espírito Santo do Pinhal

1ª Vara

Avenida 9 de julho, nº 90, Espírito Santo do Pinhal-SP - cep 13990-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1503029-94.2021.8.26.0180 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1503029-94.2021.8.26.0180

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2147145/2021 - DEL.POL.ESPIRITO STO PINHAL, 18232037 - DEL.POL.ESPIRITO STO PINHAL, 862/21/704 - DEL.POL.ESPIRITO STO PINHAL, 869/21/704 - DEL.POL.ESPIRITO STO PINHAL, 2147145 - DEL.POL.ESPIRITO STO PINHAL

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOSEMARA FRANCISCO DA SILVA e outros

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ROSELI JOSE FERNANDES COUTINHO

Vistos.

JOSEMARA FRANCISCO DA SILVA, REINALDO JOSÉ DA SILVA e JAIME HENRIQUE DA SILVA, todos devidamente qualificados nos autos, foram denunciados e estão sendo processados como incurso no artigo 33, caput, e 35, caput, ambos c.c. artigo 40, inciso III, todos dispositivos da Lei nº 11.343/06, c.c. artigo 29, do Código Penal, porque em 31 de maio de 2021, em horário não apurado, na Rua Estéfano Martini, Vila São Pedro, Município e Comarca de Espírito Santo do Pinhal, os acusados associaram-se entre si para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/06 (tráfico de entorpecentes), tendo a prática delitativa sido cometida nas imediações de estabelecimento de ensino.

Consta ainda que, no dia 31 de maio de 2021, por volta de 11h16, na Rua Estéfano Martini, Vila São Pedro, Município e Comarca de Espírito Santo do Pinhal, JOSEMARA FRANCISCO DA SILVA trazia consigo, para fins de tráfico, 04 (quatro) porções de cocaína, na forma potencializada de "crack", pesando 0,1g (um decigrama) e 01 (uma) porção de Cannabis sativa L, comumente denominada "maconha", com peso de 2g (dois gramas), substâncias consistentes em droga, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (cf. Auto de Exibição e Apreensão de fls. 88/89 e Auto de Constatação Preliminar de Substância Entorpecente às fls. 92/93), tendo REINALDO JOSÉ DA SILVA, conhecido pela alcunha de "Quick" e JAIME HENRIQUE DA SILVA, conhecido pela alcunha de "Jaimão" concorrido de qualquer forma para a prática do crime, e tendo o delito sido cometido nas imediações de estabelecimento de ensino.

Laudos Periciais às fls. 315/317 e 318/320.

A denúncia veio acompanhada do respectivo inquérito policial e foi recebida em 24 de setembro de 2021 (fls. 306/309).

A ré Josemara foi regularmente notificada (fl. 224), apresentando defesa prévia à fl. 240.

O réu Reinaldo foi regularmente notificado (fl. 232), apresentando defesa prévia à fl. 240.

O réu Jaime foi regularmente notificado (fl. 233), apresentando defesa prévia à fl. 240.

No curso da instrução foram inquiridas duas testemunhas de acusação, seguindo-se do interrogatório dos réus, tudo por meio audiovisual.

Em alegações finais, o Representante do Ministério Público requereu a procedência parcial da ação penal. O crime de tráfico de drogas restou demonstrado visto que os acusados foram flagrados em plena prática da infração livremente cometida, além da forma em que as drogas estavam acondicionadas (porções individualizadas) e variedade (crack e maconha). Lado outro, quanto ao crime de associação ao tráfico diante da inexistência de provas seguras que possam incriminar os réus, impõe-se a absolvição dos acusados, visto que não ficou comprovado o vínculo associativo duradouro, mas sim o concurso de pessoas. Quanto à reprimenda, na primeira fase, impõe-se consignar que Josemara e Reinaldo são portadores de maus antecedentes. Na segunda fase, presente a agravante da reincidência com relação aos réus Josemara e Jaime. Na terceira fase, presente a majorante prevista no artigo 40, inciso III, da Lei de Drogas. Imposição de regime de cumprimento inicial fechado.

A defesa dos acusados, por sua vez, alega que a droga apreendida é insuficiente para caracterizar o tráfico de drogas, visto que foram encontradas apenas quatro pedras de crack e uma porção de maconha, que eram para uso dos acusados. Sustentou que o acusado Reinaldo assumiu o tráfico, afastando o envolvimento dos demais (companheira e enteado), no mais afirmou que todos vivem em situação de extrema pobreza e são usuários de drogas, não justificando a condenação pelo tráfico. Devido às provas serem extremamente frágeis, requer a absolvição dos acusados.

É o relatório. Fundamento e Decido.

A pretensão punitiva é parcialmente procedente.

A materialidade delitiva restou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01 e 02), pelos boletins de ocorrência (fls. 81/84 e 85/87), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 88/89), pelo auto de constatação preliminar de substância entorpecente (fls. 92/93), pelos receituários médicos (fls. 20, 47 e 63), pelos laudos periciais (fls. 315/317 e 318/320), croqui de fls. 324, bem como pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório.

A autoria, igualmente, é certa.

Em solo policial (fl. 05), a acusada Josemara Francisco da Silva disse que é mãe de Jaime Henrique da Silva, e mulher de Reinaldo José da Silva. Informa que nesta data estava utilizando drogas juntamente com seu filho Jaime quando foram abordados pelos policiais militares. Afirma que o dinheiro encontrado com seu companheiro Reinaldo é proveniente da reciclagem, e que o simulacro de arma de fogo encontrado com ele também foi encontrado nas atividades de reciclagem. Por fim, afirma não praticar o tráfico de drogas, e que somente é usuária de crack, juntamente com Reinaldo e Jaime.

Em juízo nega a venda de entorpecentes, disse que é apenas usuária. Afirma que ela e os demais acusados compraram as drogas para o uso. Ia para o local dos fatos porque morava na rua e trabalhava capinando calçadas, além ganhar dinheiro com ferro velho e reciclagem. Conhecia dos policiais que efetuaram sua prisão, mas não tem nenhuma desavença com eles.

Em solo policial (fl. 06), o acusado Jaime Henrique da Silva disse que Josemara Francisco da Silva é sua mãe, e Reinaldo José da Silva é seu padrasto. Inquirido, nega estar envolvido com o tráfico de drogas, "nem eu, nem minha mãe, nem meu padrasto" (sic), alegando que são usuários de drogas, mais especificamente crack. Questionado, informa que nesta data, no momento em que foram abordados pelos Policiais Militares, estavam fazendo uso de crack, informando que as drogas que estavam com sua mãe seria destinada ao consumo do interrogando e dos demais, e que o valor em dinheiro que estava com Reinaldo "é do ferro velho que a gente cata" (sic).

Em juízo disse são moradores de rua e ganhavam dinheiro com ferro velho, moravam no local e são viciados em entorpecentes. Informa que comprava droga com o dinheiro que recebia do ferro velho. Nunca revendeu entorpecentes. Conhecia os policiais que efetuaram sua abordagem, mas não possuem desavenças.

Em solo policial (fl. 07), o acusado Reinaldo José da Silva disse que Josemara Francisco da Silva é sua companheira, e Jaime Henrique da Silva é filho dela. Questionado, disse que é usuário de crack, entretanto também efetua venda de parte das drogas que compra para consumir, para sustentar seu vício. Que dia 26/05/2021, adquiriu vinte pedras de crack de pessoa que não desejou informar, alegando que "eu cortei no meio todas as pedras. A metade eu usei com a Josi (referindo-se à Josemara) e com o Jaime, e a outra metade eu vendi por dez reais cada uma, no mesmo preço que eu comprei" (sic). Quanto ao simulacro, assumiu a propriedade do objeto, alegando que o usa para se defender "dos nórias que vem a noite perturbar a gente" (sic). Informou que é morador de rua, e que pernoita no local dos fatos junto com Josemara e Jaime. Relata que nesta data, estava no local do ocorrido, momento em que foram abordados pelos Policiais Militares, que localizaram quatro pedras de crack em posse de Josemara, além de valor em dinheiro, que estava com o interrogando, e o conduziram até a delegacia. Com relação ao montante em dinheiro, informa que parte dele, "é do corre, e o resto é do auxílio emergencial" (sic), não sabendo informar qual o valor exato que é oriundo do tráfico de drogas. Com relação ao seu telefone celular, autoriza o acesso ao referido aparelho, detalhando que o objeto não possui senha. Por fim, informa que as outras partes, Josemara e Jaime, não praticam a mercancia ilícita de drogas junto com o interrogando.

Em juízo disse estava voltando do banco por volta das 11h quando foi abordado pelos PM's Patente e Lino, estava com R\$ 300,00 que pegou no banco e outros valores que eram provenientes da reciclagem. Informa que são moradores de rua e vivem naquele barraco. O local é frequentado por vários usuários de droga e disse que também é usuário. Possui conta Caixa Econômica Federal e recebe "bolsa família". Acrescenta que faz uso de remédio para úlcera e não está tendo acesso ao medicamento na prisão.

Em solo policial (fl. 03), o Policial Militar Vinicius Augusto Silva Patente disse que a equipe recebeu denúncia anônima de que havia traficância de drogas em um terreno baldio na Rua Estefano Martini (próximo à escola Abelardo Cesar), Vila São Pedro. Ciente destes fatos, foi até o local para averiguar se havia movimentação ilícita juntamente com seu companheiro de farda SD PM Lino, e notaram que as pessoas de Josemara, Jaime e Reinaldo estavam realizando comércio ilícito de entorpecentes. Os mesmos já são conhecidos pelos meios policiais pela traficância ilícita de drogas, e hoje, o realizavam da seguinte maneira: Jaime ficava de frente ao terreno baldio e vendia entorpecentes para os usuários que lá passavam, Reinaldo ficava ao lado de Jaime, e guardava o dinheiro recebido em uma mochila preta, e Josemara entregava os entorpecentes a Jaime para que o mesmo vendesse, dentro de um barraco no próprio terreno baldio. Quando foi notado tal "modus operandi", a equipe iniciou a abordagem aos indivíduos, momento em que o SD PM Lino abordou Reinaldo, e o declarante abordou Jaime e Josemara, os quais estavam dentro do barraco. Insta salientar que na hora em que foi dada voz de parada a Jaime, o mesmo

correu em direção ao barraco para avisar Josemara. Com Jaime não foi encontrado qualquer entorpecente, porém com Josemara encontrou-se quatro pedras de substância análoga a crack, e uma pequena porção de maconha em suas mãos. Reinaldo que estava com a bolsa preta, possuía consigo dinheiro trocado proveniente do comércio ilícito de drogas, e um simulacro de arma de fogo na cor preta. Foi dada voz de prisão em flagrante aos três envolvidos, os quais foram encaminhados até a central de polícia judiciária.

Em juízo disse que estavam fazendo patrulhamento preventivo pelo bairro Vila São Pedro, nas proximidades da escola Abelardo César, local conhecido pelo intenso tráfico de drogas, momento em que a equipe recebeu informações vindas de moradores locais que estavam indignados com o tráfico na região, informando a mercancia ilícita próxima à referida escola. A equipe visualizou, por duas vezes, Jaime fazendo contato com possíveis usuários e se deslocava até Josemara, pegava algo entregava ao usuário e depois entregava dinheiro para Reinaldo. Não lograram êxito na abordagem dos usuários, apenas dos acusados. Com Reinaldo foi encontrado o valor de R\$ 527,00 e um simulacro que estava dentro de sua mochila, com Jaime nada de ilícito e com Josemara foram localizadas 4 pedras de crack e uma porção de maconha. Ao serem indagados, os acusados informaram que estavam traficando para manter o vício, visto que também são usuários. Ao ser questionado, Reinaldo confirmou que todo dinheiro com ele encontrado é decorrente do tráfico de drogas. Diante dos fatos foi dada voz de prisão. Os acusados já eram conhecidos dos meios policiais, mas nunca lograram êxito em abordá-los com drogas. Acredita os acusados possuem vínculo familiar e sempre estavam em locais conhecidos pelo tráfico realizando o comércio ilícito. As denúncias informavam que essa movimentação já vinha acontecendo há algum tempo, por isso os moradores da região estavam indignados. A venda dos entorpecentes acontecia perto da escola, menos de um quarteirão, o que gerava a preocupação com relação às crianças. A escola estava em funcionamento, mas devido a pandemia talvez estiassem no ambiente interno, externo havia alunos. Em solo policial (fl. 04), o Policial Militar Márcio Henrique Lino prestou depoimento idêntico ao do PM Vinicius Augusto Silva Patente, uma vez que participou de todas as diligências.

Em juízo disse que estavam em patrulhamento pelo bairro Vila São Pedro, próximo à escola Abelardo César, quando um morador informou que três indivíduos estavam efetuando a prática de tráfico de entorpecente em um terreno baldio. Deslocaram até o local fizeram o monitoramento à distância dos três acusados, oportunidade em que observaram usuários se aproximando com seus veículos, Jaime fazia contato com esses usuários, posteriormente ia até sua genitora Josemara, pegava entorpecentes e entregava para o usuário em troca de dinheiro, na sequencia entregava o dinheiro recebido para Reinaldo, que guardava os valores dentro de uma mochila. Visualizaram essa conduta por duas ou três vezes e na sequência efetuaram a abordagem dos acusados. Com Reinaldo foi localizado uma mochila e no seu interior a quantia de R\$ 527,00 em notas diversas e um simulacro de pistola, ao ser indagado informou que o dinheiro era proveniente do tráfico e o simulacro era para sua proteção, para intimidar usuários e outros possíveis traficantes. Com Josemara foram encontradas 04 pedras de crack e uma porção de maconha. Com Jaime nada de ilícito foi encontrado. Diante dos fatos foi dada voz de prisão aos acusados. Cada acusado tinha função definida na associação ao tráfico, Josemara ficava com os entorpecentes, Jaime fazia a venda, pegando o entorpecente com Josemara e levando para os usuários, enquanto Reinaldo era o responsável pelo armazenamento dos valores recebidos com a venda. A equipe já sabia sobre a existência do comércio ilícito naquela região e os acusados sempre eram vistos naquele local, Josemara inclusive dormia no barraco que montaram lá.

Quanto ao crime previsto do artigo 33, caput, c.c. artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06:

Os depoimentos dos policiais em juízo e em solo policial foram firmes, coerentes e confirmaram o recebimento de denúncia anônima apontando a traficância de drogas em um terreno baldio, próximo à escola Abelardo César. Os policiais se dirigiram até o local, onde notaram que os três acusados estavam realizando comércio ilícito de entorpecentes.

Segundo relatos dos policiais, Jaime ficava de frente ao terreno baldio e vendia entorpecentes para os usuários, Reinaldo ficava ao lado de Jaime e guardava o dinheiro recebido em uma mochila preta, por fim, Josemara armazenava os entorpecentes e os a Jaime para que efetuasse a venda. O “modus operandi” foi presenciado pelo menos por duas vezes pela equipe, que deu voz de parada aos acusados, oportunidade em que Jaime correu em direção ao barraco para avisar Josemara, sendo todos abordados em seguida. Com Josemara foram localizados entorpecentes e com Reinaldo que estava com a mochila preta, foi encontrado dinheiro trocado proveniente do comércio ilícito de drogas, e um simulacro de arma de fogo na cor preta. Informaram ainda que os acusados já eram conhecidos pelos meios policiais pela traficância ilícita de drogas.

No interior do barraco dos acusados, mais precisamente com Josemara, foram apreendidas 04 (quatro) porções de cocaína, na forma potencializada de “crack”, pesando 0,1g (um decigrama) e 01 (uma) porção de Cannabis sativa L, comumente denominada “maconha”, com peso de 2g (dois gramas). Com Reinaldo foi localizada, dentro da mochila de cor preta, a quantia de R\$ 527,40 (quinhentos e vinte e sete reais e quarenta centavos) em dinheiro trocado, além de um simulacro de arma de fogo, enquanto que com Reinaldo nada de ilícito foi encontrado.

A caracterização da traficância restou evidenciada, pois não obstante a pequena quantidade de drogas os policiais militares, após receber denúncia anônima de popular indignado com o tráfico nas proximidades da escola, fizeram campana e presenciaram pelo menos duas vendas realizadas em concurso pelos réus.

O envolvimento dos três está comprovada, eis que Jaime era responsável por contatar e negociar a venda com usuários, Reinaldo guardava o dinheiro e Josemara as drogas. Não bastassem essas provas, a traficância foi admitida em confissão parcial pelo réu Reinaldo, em solo policial. Embora não tenha sido mantida em juízo, não se pode descartar a confissão que traz inúmeros elementos circunstanciais, tais como a motivação do crime, pois o réu além de confessar que estava traficando, justificou-se dizendo que o fazia para poder sustentar o vício.

Ressalto que a condenação não está fundamentada exclusivamente em elementos colhidos durante a fase policiais, mas corroborada por provas que foram repetidas em juízo. A vedação do artigo 155 do CPP é para inviabilizar condenação fundada exclusivamente em elementos informativos colhidos na investigação. Não há vedação para que sejam utilizados elementos colhidos na investigação, mas estes não poderão ser os únicos.

No caso concreto, a condenação não está fundamentada exclusivamente na confissão parcial extrajudicial do réu, mas amparada também em depoimentos de testemunhas que em todas as vezes que foram ouvidas apresentaram relatos firmes e coerentes que não podem ser desprezados.

Além disso, foi apreendida relevante quantidade de dinheiro, produto do trafico, conforme admitido pelo réu Reinaldo em solo policial. Contudo tenha alegado em juízo a origem lícita destes valores, essa versão não foi minimamente comprovada, reforçando a sua origem ilícita e o trafico de drogas praticados pelos reus, não obstante a pouca quantidade de drogas, seguramente já tinham vendido o estoque e por isso tinham mais dinheiro que drogas com eles.

O tráfico restou configurado, sendo praticado nas imediações de estabelecimento de ensino Abelardo César, o que basta para a configuração da causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso III da Lei de Drogas.

No mais, a condição de vulnerabilidade social dos réus não exclui o crime, nem os isenta de pena. Comprovado o tráfico, a condenação é medida que se impõe.

Assim, considerando as circunstâncias em que os réus foram presos, impõe-se a aplicação da pena prevista no artigo 33, caput, c.c. artigo 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/06.

Quanto ao crime previsto no artigo 35, caput, da Lei nº 11.343/06:

A associação para o tráfico, conduta prevista no artigo 35 da Lei de Drogas não restou devidamente provada nos autos, pois não se demonstrou a existência do animus associativo, com caráter de habitualidade, estabilidade e organização, mas sim mera convergência ocasional de condutas, caracterizadora apenas da coautoria e não da associação.

Dos depoimentos prestados em juízo, não foi possível extrair a comprovação de um verdadeiro liame subjetivo entre os acusados para a prática do tráfico de entorpecentes de forma. Muito embora os policiais tenham se referido que os acusados estavam juntos no terreno baldio, não há indício de sociedade, associação ou animo associativo exigido para a configuração do delito. Portanto, não há o que se falar em associação criminosa. Não há qualquer evidência concreta de que praticam tráfico de entorpecentes juntos, embora haja indícios nesse sentido, não há provas para corroborar com essa afirmação que possam ser utilizadas para fins de se comprovar alguma estabilidade que se exige para a associação.

A parcial procedência da ação penal é medida de rigor, pois o réu deverá ser absolvido da imputação do artigo 35 da Lei de Drogas.

Passo a dosimetria da pena.

A quantidade e diversidade de droga são critérios que podem ser utilizados tanto elevação da pena base, por aplicação dos artigos 59 do CP e 42 da Lei de Drogas, quanto para dosar a diminuição de pena do §4º, do artigo 33 da lei de Drogas, em razão de ausência de critérios legais específicos para se dosar a maior ou menor de diminuição. Em qualquer circunstância não será possível a utilização dos mesmos critérios na primeira e terceira fase da dosimetria, sob pena de bis in idem. Assim, considerando que a causa de diminuição de pena é critério preponderante sobre as circunstanciais judiciais, a quantidade e diversidade de entorpecentes serão considerados na terceira fase de aplicação da pena.

Quanto à ré Josemara Francisco da Silva:

Na primeira fase, a pena-base, seguindo as diretrizes do art. 59 do Código Penal e 42 da Lei de Drogas, deve ser fixada acima do mínimo legal, pois verifico que a ré possui três condenações anteriores (fls. 281/284), sendo que uma das condenações com trânsito em julgado será dosada nesta fase como Maus antecedentes, razão pela qual aumento a pena-base em 1/6, fixando-a em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na segunda fase, ausente causa atenuante, mas presente a agravante da reincidência (fls. 117/120), razão pela qual a pena deverá ser agravada em 1/6, sendo fixada nesta fase em 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

Na terceira fase, ausentes causas de diminuição, mas presente a causa aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei de Drogas, pois a infração foi cometida nas imediações de estabelecimento de ensino, o que justifica o acréscimo de 1/6, fixando a pena em 07 (sete) anos, 11 (onze) meses e 08 (oito) dias de reclusão, além de 793 (setecentos e noventa e três) dias-multa.

O regime inicial de cumprimento da reprimenda corporal deverá ser o fechado, nos termos do artigo 2º, § 1º, da Lei 8.072/90, (redação conforme Lei 11.464/2007).

Quanto ao réu Reinaldo José da Silva:

Na primeira fase, a pena-base, seguindo as diretrizes do art. 59 do Código Penal e 42 da Lei de Drogas, deve ser fixada acima do mínimo legal, pois o réu é portador de maus antecedentes (fls. 259/260), razão pela qual aumento a pena em 1/6, fixando-a em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na segunda fase, não verifico agravantes ou atenuantes que possam alterar a pena-base.

Na terceira fase, ausentes causas de diminuição, mas presente a causa aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei de Drogas, pois a infração foi cometida nas imediações de estabelecimento de ensino, o que justifica o acréscimo de 1/6, fixando a pena em 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

O regime inicial de cumprimento da reprimenda corporal deverá ser o fechado, nos termos do artigo 2º, § 1º, da Lei 8.072/90, (redação conforme Lei 11.464/2007).

Quanto ao réu Jaime Henrique da Silva:

Na primeira fase, a pena-base, seguindo as diretrizes do art. 59 do Código Penal e 42 da Lei de Drogas, deve ser fixada no mínimo legal, pois o réu possui uma condenação anterior a qual configura reincidência (fls. 265/266), portanto nesta fase, não há elementos nos autos para se aferir possuir maus antecedentes, sendo certo que a reincidência será dosada na segunda fase, assim fixo a pena-base no mínimo legal, resultando em 05 (cinco) anos de reclusão, além de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, ausentes atenuantes, mas verifico a agravante da reincidência (fls. 265/266), motivo pelo qual aumento a pena em 1/6, fixando-a em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na terceira fase, ausentes causas de diminuição, mas presente a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei de Drogas, pois a infração foi cometida nas imediações de estabelecimento de ensino, o que justifica o acréscimo de 1/6, fixando a pena em 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

O regime inicial de cumprimento da reprimenda corporal deverá ser o fechado, nos termos do artigo 2º, § 1º, da Lei 8.072/90, (redação conforme Lei 11.464/2007).

O crime em concreto praticado pelos réus é deveras grave e, por isso mesmo, nem guardam compatibilidade com aquelas sanções mais brandas previstas no sobredito dispositivo legal. Quando do julgamento do Habeas Corpus nº 203.403/SP, aliás, a 5ª Turma do C. Superior Tribunal de Justiça, relator o eminente Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, assentou que não parece razoável que o condenado por tráfico de entorpecentes, seja ele de pequeno, médio ou grande porte, seja beneficiado com essa substituição, porque, em todas as suas modalidades, trata-se de delito de extrema gravidade e causador de inúmeros males para a sociedade, desde a desestruturação familiar até o incentivo a diversos outros tipos de crimes gravíssimos, que, não raro, têm origem próxima ou remota no comércio ilegal de drogas, sem falar do problema de saúde pública em que já se transformou (HC 203.403/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 01/07/2011).

No mesmo sentido o v. aresto proferido em data deveras recente pela C. 4ª Câmara Criminal do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo nos autos da apelação nº

0020420-98.2010.8.26.0576, relator o eminente Desembargador Salles Abreu, para quem atualmente, o entendimento majoritário do Colendo Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do artigo 44, da Lei 11.343/06, possibilitando, em um caso concreto, a conversão da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos. No entanto, o crime continua grave e hediondo, sendo que a substituição penal não se mostra suficiente para a reprovação e prevenção do delito, portanto, não deverá ser aplicada no caso em tela, afastado o pedido subsidiário (Apelação nº 0020420-98.2010.8.26.0576 - São José do Rio Preto - 4ª Câmara Criminal - Relator: Salles Abreu - 04/10/2011).

E ainda:

PENA - Restritivas de direitos - Tráfico de entorpecentes - Incompatibilidade com a determinação legal de regime fechado (art. 2º, parágrafo 1º, da Lei nº 8.072/90) - Inaplicabilidade dos benefícios da Lei nº 9.715/98 - Recurso improvido (Apelação Criminal nº 877.915-3/8 - São Paulo - 6ª Câmara Criminal - Relator: Marco Antonio - 17/08/2006 - V.U.).

PENA - Restritivas de direitos - Réu condenado por tráfico de entorpecentes - Substituição da reprimenda privativa de liberdade - Inadmissibilidade - Preliminares rejeitadas e recurso improvido (Apelação Criminal nº 908.095.3/3 - São Paulo - 9ª Câmara Criminal - Relator: Ubiratan de Arruda - 27/09/2006 - V.U.).

Ante o exposto, julgo o pedido da ação penal PARCIALMENTE PROCEDENTE, para (i) CONDENAR a ré JOSEMARA FRANCISCO DA SILVA, RG: 37.437.568, nascida em 01/06/1976, natural de Espírito Santo do Pinhal, filha de Benedito Francisco da Silva e Helena Aparecida dos Santos Silva, como incurso no artigo 33, caput, c.c. artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06, ao cumprimento da pena de 07 (sete) anos, 11 (onze) meses e 08 (oito) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 793 (setecentos e noventa e três) dias-multa, mantido o valor unitário do dia-multa no mínimo legal; (ii) CONDENAR o réu REINALDO JOSÉ DA SILVA, RG: 26.030.501, nascido em 16/02/1967, natural de Jacutinga, filho de Antônio José da Silva e Maria Cândida Silva, como incurso no artigo 33, caput, c.c. artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06, ao cumprimento da pena de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, mantido o valor unitário do dia-multa no mínimo legal; (iii) CONDENAR o réu JAIME HENRIQUE DA SILVA, RG: 41.077.307, nascido em 26/08/1994, natural de Espírito Santo do Pinhal, filho de Josemara Francisco da Silva, como incurso no artigo 33, caput, c.c. artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06, ao cumprimento da pena de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, mantido o valor unitário do dia-multa no mínimo legal; (iiii) ABSOLVER os réus JOSEMARA FRANCISCO DA SILVA, REINALDO JOSÉ DA SILVA e JAIME HENRIQUE DA SILVA da imputação do artigo 35, caput, da Lei nº 11.343/06, nos termos do artigo 386, VII do Código de Processo Penal.

Subsistindo os pressupostos, fundamentos e condições de admissibilidade que fundamentaram a decretação da prisão preventiva dos réus, em especial a ordem pública, o risco a instrução processual e possibilidade de se furta a aplicação da lei penal, entendo que os réus deverão permanecer presos cautelarmente.

Reconhecido o tráfico, de rigor o decreto de perda dos valores apreendidos em favor da União.

Pagamento da taxa judiciária, nos termos da Lei Estadual de Custas, as expensas do condenado. Transitada em julgado, lancem-se os nomes dos réus no Rol dos Culpados e oficie-se à SENAD, nos termos do art. 63, §4º da lei de 11.343/2006.

P.I.

Espirito Santo do Pinhal, 31 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA